

《【문제1】 甲(수원에 주소를 두고 살고 있음)은 대전에 소재한 자기 토지를 乙(대구에 주소를 두고 살고 있음)에게 매도하고 매매잔대금 1억 원을 받지 못하여, 그 지급을 구하는 소를 대전지방법원에 제기하였다. 이후에 甲은 乙이 소제기 이전에 사망하였다는 사실과 乙의 유일한 상속인인 丙(대구에 주소를 두고 살고 있음)이 있다는 사실을 알게 되었다. 甲은 피고를 丙으로 바꾸는 신청을 하였고 법원은 당사자표시정정하여 피고를 丙으로 바꾸었다. 다음 물음에 답하시오. (50점) (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임)

(물음2) 丙은 이 사건 법원의 당사자표시정정은 부적법하다고 주장하였다. 丙의 이 주장이 타당한지를 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 소제기 전 사망자를 피고로 한 경우 당사자표시정정의 적법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 원고 甲이 피고 乙의 사망 사실을 모르고 소를 제기한 후 상속인 丙으로 당사자표시정정을 신청하여 법원의 허가를 받았으며, 이에 피고 丙은 당사자표시정정이 부적법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <사자 상대 소송의 보정 방법으로서 당사자표시정정이 허용되는지 아니면 민사소송법 제260조의 피고경정을 거쳐야 하는지> 검토해야 한다. 이하에서는 이와 관련한 당사자확정 및 피고 경정·표시정정 법리를 고찰하고 사안에 대입하여 丙의 주장 타당성 여부를 논한다.

II. 당사자확정 및 피고 사망 시의 보정 법리

1. 당사자의 확정 기준과 사자 대 상속인의 관계

(1) 당사자확정의 기준의 학설과 판례

- 소송 당사자 확정 기준에 대하여는 원고의 주관적 의사를 기준으로 하는 의사설, 소장 기재 표시를 기준으로 하는 표시설, 실제 소송 행위자를 기준으로 하는 행동설이 대립한다. “대법원”은 소장의 전체적인 기재와 청구 내용 등을 종합하여 합리적으로 당사자를 확정하는 규범적 표시설(실질적 표시설)을 취한다.

(2) 소제기 전 사망한 경우의 당사자확정

- 실질적 표시설에 의할 때, 원고가 피고의 사망 사실을 모르고 사자를 피고로 표시하여 소를 제기한 경우, 원고의 실질적 의사는 상속인을 상대로 분쟁을 해결하려는 것이다. 따라서 표시에도 불구하고 실질적 피고는 처음부터 상속인으로 확정된다.

2. 사망자를 피고로 한 소송의 보정 방법

(1) 당사자표시정정설 (판례의 입장)

- “대법원”은 소제기 전 사망자를 피고로 삼은 소송은 원칙적으로 부적법하다고 본다. 다만, 원고가 선의인 경우 실질적 피고는 상속인이고 단지 표시의 오류에 지나지 않으므로, 상속인으로서의 당사자표시정정을 허용한다. 이 경우 제소의 효과는 최초 소장 제출 시로 소급하여 발생한다.

(2) 피고경정설 (학설의 비판)

- 일부 학설은 사망한 사자에서 상속인으로 당사자를 바꾸는 것은 당사자의 동일성을 해치는 변경이라고 비판한다. 따라서 “민사소송법 제260조”의 피고경정 요건과 절차를 거쳐 피고를 변경해야 하며, 표시정정을 허용하는 판례의 태도는 타당하지 않다고 주장한다.

III. 사안의 적용

1. 실질적 피고의 확정 및 동일성 범위

(1) 실질적 피고의 확정

- 원고 甲은 피고 乙이 소제기 전 이미 사망한 사실을 모르고 매매잔대금 청구소송을 제기하였다. 실질적 표시설을 취하는 판례에 따를 때, 甲의 실질적 의사는 乙의 유일한 상속인인 丙을 피고로 삼으려는 것이므로, 실질적 피고는 처음부터 상속인 丙으로 확정된다.

(2) 당사자의 동일성 인정 여부

- 사망자 乙과 유일한 상속인 丙은 분쟁의 실제적 귀속 관계에서 실질적으로 동일한 주체로 평가된다. 따라서 피고의 명의를 乙에서 丙으로 변경하는 것은 당사자의 명백한 오기를 바로잡는 당사자표시정정의 범위 내에 포섭된다.

2. 당사자표시정정의 적법성 및 丙의 주장 판정

(1) 당사자표시정정의 적법성

- 甲은 乙의 사망 사실을 안 이후 피고를 丙으로 변경하는 당사자표시정정을 신청하여 법원의 허가를 받았다. 판례에 따를 때, 소제기 전 사망자를 피고로 오기한 경우 상속인 丙으로서의 당사자표시정정은 정당한 보정 방법으로서 전적으로 적법하다.

(2) 피고 丙의 주장의 타당성 검토

- 피고 丙은 당해 당사자표시정정이 동일성을 해쳐 부적법하다고 주장하나, 이는 성문법상의 피고경정만을 고집하는 비판론에 불과하다. 실질적 피고가 상속인 丙으로 확정된다는 판례에 비추어 볼 때, 丙의 이러한 독자적 주장은 법리적으로 타당하지 않다.

IV. 결론

- 선의의 원고 甲이 소제기 전 사망한 乙을 피고로 삼은 경우, 실질적 피고는 처음부터 상속인 丙으로 확정되므로 乙에서 丙으로 피고를 변경하는 당사자표시정정은 소송법상 전적으로 적법하다. 따라서 법원의 당사자표시정정이 부적법하다는 피고 丙의 항변은 타당하지 않다. 법원은 丙의 주장을 배척하고 본안 심리를 진행하여야 한다.